

0001912-47.2008.8.26.0068

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réus:

Jefferson Lopes Damico e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Jefferson Lopes Damico e Paulo Sergio Souza dos Santos, qualificado(s) nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 porque no dia 15 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Dr. Paulo de Arruda Baccarat nº 140, Barueri - SP - cep 06410-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001912-47.2008.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001912-47.2008.8.26.0068

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réus:

Jefferson Lopes Damico e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Jefferson Lopes Damico e Paulo Sergio Souza dos Santos, qualificado(s) nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 porque no dia 15 de janeiro de 2008, por volta das 04h 00min, na Rodovia Castello Branco, nesta cidade e comarca de Barueri, transportavam 75 pacotes de cocaína, pesando 75,256 kg, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.15/17), assim como o laudo de constatação (fl.18), o laudo de exame químico-toxicológico (fls.111/112) e

o relatório sumário de transcrições (fls.118/121).
A denúncia foi recebida em 11 de junho de 2008 (fls.221/223).
Os réus foram citados e interrogados (fls.234/235). Depois disso eles apresentaram defesa (fls.186/187 e 207/209).
Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas da acusação (fls.236/238) e três da defesa (fls.239/241).
As partes apresentaram alegações finais (fls.339/343).
Foi proferida sentença condenatória (fls.358/370).
O réu Jefferson opôs embargos de declaração (fl.393), os quais não foram conhecidos (fl.394).
O réu Paulo interpôs recurso de apelação (fls.405 e 410/426). As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público (fls.428/432).
Os réus foram postos em liberdade em virtude de HC concedido pela 12a Câmara de Direito Criminal do TJSP (fl.22 do apenso), por isso foram intimados por edital (fl.453).
O TJSP deu provimento ao recurso para anular a sentença (fls.572/580). Em razão disso, foi determinada a expedição de ofício à Delegacia de Polícia para juntada de documentos e a verificação por parte da Serventia dos autos da interceptação telefônica (fl.586).
Foram juntados aos autos documentos oriundos da Delegacia de Polícia (fls.592/594). Manifestaram-se as partes acerca disso (fls.595 e 599/600).
Foi deferido o pedido do Ministério Público para expedição de ofício para a 15a Vara Criminal da Capital para envio das interceptações telefônicas (fl.598). O referido juízo informou que não havia interceptação (fl.608).
O Ministério Público reiterou os memoriais anteriormente apresentados (fl.670).
A defesa dos réus Jefferson e Paulo Sérgio apresentou novos memoriais (fls.673/723 e 738/741).
É o relatório. Decido.
Fl.590: Anote-se.
A sentença anteriormente proferida pela colega que me antecedeu na titularidade desta Vara foi anulada em razão de falta de análise da tese defensiva sustentada pelo réu Paulo Sérgio. Consta o seguinte do v.Acórdão:

"(...) Entretanto, tenho para mim que a r.sentença encontra-se inquinada de nulidade, uma vez que a não enfrentou a tese trazida pela defesa do corréu Paulo Sérgio, em sede de memoriais finais, às fls.349/356, acerca da interceptações (sic) telefônicas procedidas sem a devida autorização judicial, o que impede que seja agora abordada em sede apelação, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição".

A questão referente à inversão da ordem de produção da prova foi rechaçada em primeiro grau e isso foi mantido em segundo grau, então não entendo que se faz necessário repisar o tópico.

Sob essa ótica, entendo que pode ser perfeitamente proferida nova sentença de imediato, desde que analisada a referida preliminar. É o que passo a fazer.

O réu Paulo Sérgio questionou com precisão em preliminar de alegações finais que não houve autorização judicial para as interceptações telefônicas a que fez menção o Ministério Público na denúncia, de tal modo que seriam absolutamente nulas todas as provas obtidas a partir delas, inclusive a diligência ocorrida no dia dos fatos, que culminou com a prisão dele.

Observando os autos, confirmo que não consta de seu conteúdo a autorização judicial que teria sido proferida em sede de inquérito policial. Aliás, nem mesmo o inquérito policial em que teria sido deferida judicialmente a interceptação telefônica consta dos autos. E oficiado à vara criminal da capital por onde teria tramitado o processo decorrente desse inquérito policial para que remetesse a este juízo o que tivesse ainda sobre a interceptação telefônica em tela, a resposta foi de que inexistiu interceptação telefônica nos autos indicados.

Ora, ausente comprovação de que existiu interceptação telefônica autorizada judicialmente, é evidente que a prova é ilícita e, a rigor, por conta do disposto

no artigo 157 do Código de Processo Penal, todas as demais provas também o são. Não o seriam apenas se estivesse presente ao menos uma das duas exceções legais: se não evidenciado haver nexo de causalidade entre umas e outras provas ou se as provas derivadas pudessem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Interpretando o referido preceito normativo o STJ assentou o seguinte em julgado recente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. CONVERSAS POR MEIO DE APLICATIVO WHATSAPP. ACESSO SEM AUTORIZAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES CAPAZES DE SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "a ilicitude da prova, por reverberação, alcança necessariamente aquelas dela derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), salvo se não houver qualquer vínculo causal com a prova ilícita (Teoria da Fonte Independente) ou, mesmo que haja, seria produzida de qualquer modo, como resultado inevitável das atividades investigativas ordinárias e lícitas (Teoria da Descoberta Inevitável)" (EDcl no RHC n. 72.074/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/12/2017, grifei). A regra de exclusão (exclusionary rule) das provas derivadas das ilícitas consubstanciada na teoria da descoberta inevitável (inevitable discovery), que tem origem no direito norte-americano, foi recebida no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 11.690/2008.

III - Desse modo, conquanto haja prova ilícita nos autos, as demais provas incriminatórias seriam, infalivelmente, obtidas pelo desenvolvimento regular, lícito e ordinário das atividades investigativas, as quais não se maculam pela ilicitude da prova originária. Portanto, se preservam como fonte idônea para comprovação de materialidade e de autoria delitiva. In casu, as instâncias ordinárias afirmaram que a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas "pelo auto de apreensão (...) e laudo toxicológico (...). A autoria, do mesmo modo, é inconteste. Embora o apelante negue a propriedade das drogas, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontradas 09 (nove) tablets de maconha próximo a residência de Juliano, o que restou demonstrado pelo auto de apreensão e pelos depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências que culminou na prisão do acusado". Não é outro o entendimento do Ministério Público Federal sobre o caso: "[...] Nesse ponto, cumpre destacar da sentença o fato de que antes mesmo da apreensão do indigitado aparelho celular, havia um trabalho de cooperação investigativa entre a polícia civil e a polícia militar, de modo que a conclusão sobre o cometimento dos crimes a que chegaram as autoridades não seria diferente acaso não estivessem em posse do aparelho. [...]. Todo o exposto leva à conclusão de que as provas guardam a legalidade e a higidez necessárias e suficientes à comprovação da materialidade e autoria delitivas. (...)."

(STJ - 5a T., AgRg no HC 638935 / MG, rel. Min. Félix Fischer, j. 30.03.2021, DJe 09.04.2021)

O fato de ser eventualmente considerada prova emprestada, por si só, não altera o panorama acima porque a aplicação analógica do artigo 372 do Código de Processo Civil, como permite o disposto no artigo 3o do Código de Processo Penal, deve ser interpretado sob a ótica penal da reserva de jurisdição.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, caberia ao Ministério Público alegar e comprovar a presença de uma dessas duas exceções legais. No entanto, ele não se desincumbiu desse ônus.

Com efeito, todas as peças informativas colhidas durante o inquérito policial e as provas obtidas durante a instrução processual, especialmente as de natureza oral, mostraram que a abordagem do caminhão derivou única e exclusivamente da suposta interceptação telefônica. Houve relação de causa e efeito direta.

Os policiais, sempre que ouvidos, explicaram que investigavam a prática dos crimes e certo dia interceptaram uma ligação do réu Paulo Henrique de Souza, membro de quadrilha, na qual ficaram sabendo que ele estava indo para Guararapes, cidade de Ricardo e do réu Jefferson, para tratar sobre uma carga de drogas. O telefone do réu Paulo também foi interceptado e, por vários dias, obteve-se informações relacionadas ao tráfico. Por conta das investigações descobriu-se que um caminhão saía daquela cidade transportando entorpecentes e então ele foi interceptado na referida rodovia pelos policiais. Num fundo falso do reboque foram encontradas as drogas e, com os réus, os telefones celulares cujas linha tinham sido interceptadas anteriormente.

Não havia qualquer medida investigativa diversa que poderia levar à abordagem do caminhão onde estavam as drogas. Os depoimentos dos policiais são viciados porque fundados em prova ilícita, assim como as drogas e tudo o mais que foi apreendido. Não há prova que não tenha sido viciada, de tal modo que é inescapável a conclusão de que os réus devem ser absolvidos por falta de prova lícita da

autoria/participação e materialidade dos crimes imputados a eles na denúncia. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para ABSOLVER os réus Jefferson Lopes Damico e Paulo Sergio Souza dos Santos, da acusação fundada nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à autoridade policial informando a liberação para a definitiva incineração dos entorpecentes e a adoção do disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal com relação aos demais bens apreendidos.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

P.R.I.C.

Barueri, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA